

1500241-35.2022.8.26.0613

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: JOSE ALFREDO DE ANDRADE FILHO

Comarca: Casa Branca

Foro: Foro de Casa Branca

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.

1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Casa Branca

Foro de Casa Branca

2ª Vara

Praça Ministro Costa Manso, 78, Casa Branca-SP - cep 13700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500241-35.2022.8.26.0613 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500241-35.2022.8.26.0613

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2164590/2022 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 25610761 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 2164590 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 2164590 - DEL.POL.CASA BRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ROBERTO NEGRINI e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE ALFREDO DE ANDRADE FILHO

Vistos.

MARCOS ROBERTO NEGRINI foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque, no dia 18 de junho de 2022, aproveitando-se do repouso noturno, por volta de 01h30min, na Rua Coronel José Júlio, 806, Jardim Paulista, cidade e Comarca de Casa Branca, agindo com unidade de designios e identidade de propósitos com outro indivíduo não identificado, mediante arrombamento, subtraiu, para proveito comum, coisas alheias móveis, consistentes em 02 (dois) aparelhos celulares da marca LG K12, 01 (uma) frigideira, 01 (uma) barra magnética de imã para facas, marca Top House, 02 (dois) pulverizadores, marca Clink, 01 (uma) luva tática, marca JYX, 01 (um) suporte para tornozelo, marca C41315, e 34 (trinta e quatro) cartões bancários, marca

Mastercard, tudo avaliado em R\$ 2.575,40 (dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos) e pertencentes ao estabelecimento comercial denominado "Magazine Luiza".

A denúncia foi recebida (fls. 82/83). Após, o réu foi citado (fl. 141) e apresentou resposta à acusação (fls. 121/124). Durante a fase instrutória, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Ao final, o acusado foi interrogado.

Superada a fase de diligências, em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, preliminarmente, alegou nulidade das provas, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada, tendo em vista que as provas constantes nos autos decorreram de reconhecimento realizado em desobediência ao artigo 226 do Código de Processo Civil; e, também, a invalidade do vídeo juntado aos autos, porque não periciado. No mérito, solicitou, caso acolhida a preliminar, a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão; a aplicação da pena-base no mínimo legal; a fixação do regime aberto; e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, solicitou a concessão de liberdade provisória.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, a preliminar arguida pela combativa Defesa, no sentido da ocorrência de nulidade em razão da inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal não merece prosperar. Também não há falar-se em nulidade das provas, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada, tendo em vista que as provas constantes nos autos teriam de reconhecimento realizado na fase policial.

Impende sobressaltar que "A teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits of the poisonous tree) e a doutrina da fonte independente (independent source doctrine) são provenientes do mesmo berço, o direito norte-americano. Enquanto a primeira estabelece a contaminação das provas que sejam derivadas de evidências ilícitas, a segunda institui uma limitação à primeira, nos casos em que não há uma relação de subordinação causal ou temporal (v. *Silverthorne Lumber Co v. United States*, 251 US 385, 40 S Ct 182, 64 L.Ed. 319, 1920 e *Bynum v. United States*, 274, F.2d. 767, 107 U.S. App D.C 109, D.C.Cir.1960)" (RHC n. 46.222/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 3/2/2015, DJe de 24/2/2015).

Demais disso, "a ilicitude da prova, por reverberação, alcança necessariamente aquelas dela derivadas (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada), salvo se não houver qualquer vínculo causal com a prova ilícita (Teoria da Fonte Independente) ou, mesmo que haja, seria produzida de qualquer modo, como resultado inevitável das atividades investigativas ordinárias e lícitas (Teoria da Descoberta Inevitável)" (EDc1 no RHC n. 72.074/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/12/2017).

A doutrina da fonte independente encontra amparo normativo no art. 157, §2º, do CPP:

"§ 2o Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova".

No caso em apreço, o réu confessou em juízo e sua confissão foi corroborada pela prova oral colhida em solo judicial, de modo que a autoria delitiva passa a ser estabelecida por essas provas, e não pelo reconhecimento feito na fase inquisitorial. Ainda que afastado o reconhecimento na fase policial, há provas

produzidas em juízo (confissão espontânea e prova testemunhal) apontando para a autoria delitiva.

Logo, ainda que se considerasse, apenas a título de argumentação, a mácula na identificação ocorrida na fase policial, ainda assim há prova suficiente da autoria.

De mais a mais, há de prevalecer a identificação feita na fase policial, corroborada pelas declarações das testemunhas arroladas pelo Ministério Público em Juízo, mesmo porque o artigo 226 do CPP prevê a possibilidade do reconhecimento "Quando houver necessidade" (caput), preconizando que serão colocadas outras pessoas semelhantes "se possível" (inciso II).

E a falta da observância das formalidades do artigo 226 do CPP por si só não configura nulidade, mormente porque, no caso concreto, o conjunto probatório como um todo é coeso e coerente quanto à autoria delitiva, conformando, destarte, a identificação feita pelas testemunhas em solo policial.

Cediço, ainda, que eventual vício ocorrido no inquérito policial não contamina a ação penal, máxime porque a identificação feita pelas testemunhas na fase policial foi ratificada em suas declarações em Juízo.

Nesta mesma diretriz de pensamento, tenha-se presente que o Policial Militar Gustavo João Otávio Sarraf Generoso, em juízo, afirmou que, após a abordagem do acusado, que possuía as mesmas características passadas pela testemunha José Lucas da Silva, identificou-o pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial. No mesmo sentido, a referida testemunha também disse, sob a égide processual, que identificou o réu pela câmera de segurança.

Em verdade, as testemunhas identificaram o acusado na fase policial. Em Juízo, sob o crivo do contraditório, endossaram a identificação realizada na fase inquisitiva.

Ademais, todo o contexto e as circunstâncias fáticas corroboram a autoria imputada ao acusado, conforme se verá mais adiante.

O mais recente entendimento do C. STJ sobre a questão do reconhecimento de pessoas no processo penal está assim ementado:

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.

1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.

5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão.

6. A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem. A identificação do perfil na rede social facebook foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social.

7. Agravo regimental improvido".

(AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022.)

Percebe-se, portanto, que o próprio C. STJ amenizou as diretrizes do decidido no HC n. 598.886/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020.

No que toca à alega invalidade do vídeo acostados aos autos, em razão de não ter sido periciado, entendo que a ausência de exame pericial não acarreta, por si só, a invalidade da prova, mas apenas reflete no seu valor probatório.

Por tais motivos, rejeito a preliminar de nulidade e a declaração de invalidade do vídeo juntado aos autos.

No mérito, trata-se de ação penal, em cujo processo apura a autoria e materialidade do episódio delitivo narrado na denúncia.

Finda a fase instrutória, a procedência da pretensão punitiva nesta ação penal é medida de rigor.

A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas por intermédio do auto de prisão em flagrante (fls. 01 e seguintes), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), pelo auto de entrega (fls. 16/17), pelos laudos periciais de fls. 91/100 e 128/132 e pela prova oral produzida durante a instrução.

A autoria também é certa e deve ser atribuída aos acusados.

A representante legal da empresa vítima, Elisangela Cristina Batista, narrou, em resumo, que, no dia dos fatos, o acusado e mais uma pessoa invadiram o estabelecimento comercial, "arrebentando a porta". Foram subtraídos produtos de clientes, celulares e cartão. Posteriormente, os policiais prenderam o acusado no momento. Os produtos dos clientes foram resgatados. Teve prejuízo em razão dos danos físicos no prédio, em torno de R\$ 2.000,00. O furto ocorreu de madrugada. O furto foi cometido pelo acusado e mais uma pessoa que não foi localizada. Tal pessoa subtraiu mais de 40 cartões de crédito e dois celulares de uso da loja, os quais não foram recuperadas. Referidos cartões foram cancelados. O réu foi identificado pela câmera de segurança. Já viu o réu passar na loja e na rua. Os Policiais Militares o identificaram nas câmeras. Assim que os policiais entraram na loja, já lhes entregou a câmera de segurança.

Em seguida, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público foram ouvidas sob a égide processual.

O Policial Militar Gustavo João Otávio Sarraf Generoso disse, em síntese, que, no dia dos fatos, foram informados que estava havendo um furto na loja Magazine Luiza. No local, um popular contou-lhes que tinha visto os furtadores saindo da loja e passou-lhes as características deles. Em seguida, realizaram patrulhamento e encontraram o réu, que possuía as mesmas características passadas. Antes de ser abordado, o réu tentou se evadir e dispensou alguns objetos, sendo um deles com embrulho da loja Magazine Luiza. O réu já era conhecido pela prática de furtos.

Disse que já conhecia pelo réu pela prática de em torno de quinze furtos. Confirmou que era o acusado pelas câmeras de segurança, em razão das vestes. , O réu confirmou a prática do furto e quem era seu comparsa. Após a prisão do réu, cessaram os furtos na cidade. Esclareceu que a testemunha José Lucas da Silva avistou o réu e apontou-lhes as características.

A testemunha José Lucas da Silva narrou, em resumo, que, passando próximo ao local dos fatos, avistou dois indivíduos correndo, saindo da loja Magazine Luiza. Disse que a porta da loja estava arrombada. Informou as características dos indivíduos aos policiais. Conseguiu identificar o acusado pelas imagens da câmera de segurança.

Ao final, o acusado, sob o crivo do contraditório, foi interrogado. Admitiu que é verdadeira a acusação. Afirmou que cometeu o delito, por causa da abstinência de drogas. Disse que, se houver possibilidade, tem o interesse em pagar o prejuízo da vítima. Disse que o furto ocorreu no período noturno. Estava ele e mais uma pessoa. Não se recorda se a outra pessoa arrombou a porta. Foi abordado duas horas depois. Os bens subtraídos ficaram com a outra pessoa. Não tem nada contra a representante da vítima e contras as testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

Como se vê, a versão da representante da vítima e das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, aliada à própria confissão do réu, apontam, com segurança, este como um dos autores do furto em questão.

Ressalte-se que a confissão é circunstância atenuante genérica e também meio de prova, sobretudo quando se mostra em consonância com a prova produzida sob o crivo do contraditório, o que ocorre no caso dos autos.

Assim, da análise do conjunto probatório, tem-se incontroverso o acusado, na companhia de outra pessoa não identificada, que praticou os fatos narrados na denúncia, de forma que a confissão judicial corrobora as demais provas produzidas nos autos.

No que tange às qualificadoras de concurso de agentes e rompimento de obstáculo, estas devem ser reconhecidas, uma vez que a prova oral produzida sob o crivo do contraditório confirmaram-nas e, quanto à última, foi constatada no laudo pericial de fls. 91/100.

Quanto à causa de aumento do repouso noturno, esta não incide na espécie, uma vez que estamos diante de furto duplamente qualificado, em conformidade com o Tema Repetitivo 1087 do C. Superior Tribunal de Justiça: “A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”.

Acrescente-se que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo vem aplicando o referido tema:

“(...) Repouso noturno – Afastamento – Inaplicável a majorante às hipóteses de furto qualificado – Nova posição do STJ sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1087. 5. Regime inicial – Alteração para semiaberto – Opção não obstada pela reincidência nem pelos maus antecedentes, resultantes de fato antigo. 6. Substituição – Medida socialmente recomendável, não decorrendo a recidiva do mesmo crime. (TJSP; Apelação Criminal 0001714-02.2018.8.26.0604; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sumaré - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/09/2022; Data de Registro: 08/09/2022).

Furto qualificado – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Inaplicável o princípio da insignificância – Afastada a causa de aumento de pena do repouso noturno em virtude do entendimento pacificado do Superior Tribunal de

Justiça (Tema 1087) - Pena redimensionada - Mantida a substituição da pena de reclusão pela de detenção devido ao privilégio reconhecido em primeiro grau - Regime semiaberto mantido - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500355-30.2019.8.26.0111; Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cajuru - Vara Única; Data do Julgamento: 06/09/2022; Data de Registro: 06/09/2022)

Nesse contexto, restou comprovado que o réu, em concurso com pessoa não identificada, praticou o delito de furto mediante rompimento de obstáculo, de modo que a procedência do pedido condenatório é medida de rigor.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, tendo em vista que, no presente caso, estão presentes duas qualificadoras (concurso de agentes e rompimento de obstáculo), considero duas delas no primeiro estágio da calibragem da sanção, de modo que aumento a pena-base em 1/6 (um terço).

Nada há mais para ser considerado nesta etapa, tendo em vista o acusado é somente reincidente, circunstâncias que será valorada na próxima etapa.

Na segunda fase, incide a circunstância agravante da reincidência, o réu possui uma condenação definitiva anterior, a qual lhe acarreta essa circunstância, tendo em vista que consta que a pena foi cumprida ou julgada extinta em 25/07/2017 (Proc. 0004847-81.2002.8.26.0129 - fl. 34). Não obstante, considerando que o acusado confessou os fatos, tendo tal confissão sido utilizada na formação de convencimento deste Magistrado, à luz da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, fica a agravante da reincidência compensada com a da confissão.

Na terceira fase não há causa de aumento ou diminuição.

Ante a reincidência, não há que se falar em privilégio.

Assim, atento a esses critérios, fixo a pena definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Fixo o dia-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente desde então, em face da ausência de dados quanto à situação econômica dos réus.

Em relação ao regime inicial para início de cumprimento de pena, a circunstância judicial negativa e a reincidência demandam a fixação do regime fechado.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 12.736/2012, porque o regime inicial não foi fixado em virtude da quantidade de pena aplicada.

Tendo em vista a circunstância judicial negativa e a reincidência, entendo que o acusado não faz jus aos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

As demais alegações não comportam outras considerações ou digressões, por haver incompatibilidade lógica com o quanto já mencionado. Como é sabido, o órgão julgador não está obrigado a responder todas as alegações ou se referir, um a um, a todos os seus argumentos. Com efeito, "o que a Constituição exige é que o juiz ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as alegações dos réus, mas tão-somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão" (STF, HC nº 82.746-SP). No mesmo sentido:

"Não se tem como omissa a sentença condenatória que, embora não se referindo,

expressamente, à tese da defesa, fundamenta a condenação com base nos elementos probatórios reputados válidos para caracterizar o crime narrado na denúncia e sua autoria. (...). Embora seja necessário que o Magistrado aprecie todas as teses ventiladas pela defesa, torna-se despiciendo a menção expressa a cada uma das alegações se, pela própria decisão condenatória, resta claro que o julgador adotou posicionamento contrário" (STJ, RHC nº 12.842-0/PR).

Assim, a soma de alegações choca-se contra os fatos verificados nos autos, e conseqüentemente, são afastados os argumentos restantes, por inaplicáveis.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para o fim de condenar o acusado MARCOS ROBERTO NEGRINI, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 dias-multa, cada dia-multa no piso de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Custas na forma da lei (artigo 804 do CPP c/c artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003).

O acusado não poderá apelar em liberdade, visto que subsistem os motivos que ensejaram a decretação de sua custódia cautelar. Muito a propósito disso, a prova produzida sob os auspícios do contraditório corrobora a manutenção da prisão cautelar decretada quando de sua prisão em flagrante. Não se verifica alteração do quadro que motivou a segregação preventiva. Ainda estão presentes circunstâncias de fato e de direito necessárias para manutenção da prisão do acusado. As circunstâncias e o cenário fático que ensejaram a decretação da prisão preventiva restaram confirmados no curso da instrução e, portanto, os motivos que ensejaram a custódia cautelar permanecem intactos e incólumes. Ademais, na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art.312 do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC 116.112/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T. STJ, DJe 10/12/2019). Recomende-se-o na prisão em que se encontra.

Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, considerando que o Ministério Público formulou, na inicial acusatória, o pedido de indenização em favor da vítima, bem como que o próprio réu afirmou, em seu interrogatório, que tem o desejo de pagar o prejuízo suportado por ela, fixo como valor mínimo o montante de R\$2.000,00 - quantia fixada de acordo com o relato da representante da vítima em juízo - para reparação dos danos materiais causados pela infração, importância a ser corrigida monetariamente pelos índices da tabela prática de atualização de débitos judiciais do E. TJSP, desde a data dos fatos, por se tratar de prejuízo de ordem material.

Intime-se a vítima do conteúdo desta sentença (art. 201, §2º, do CPP, com alteração ditada pela Lei nº 11.690/2008).

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da CF, bem como ao IIRGD.

Ao D. Defensor nomeado, arbitro honorários no máximo da tabela do convênio DPE-SP/OAB-SP.

P.I.C. Dispensado o registro (Provimento CG nº 27/2016).

Casa Branca, 09 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA